

1501471-91.2021.8.26.0599

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Flavia de Cassia Gonzales de Oliveira

Comarca: Piracicaba

Foro: Foro de Piracicaba

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 26/01/2022

... Ygor confessou que era seu primeiro dia no tráfico, e ganharia\$ 20,00 por cada mula vendida (que são 26 unidades de crack) e cada pedra, estava sendo vendida por R\$5,00. Quanto a Felipe, confessou que tem condenações por tráfico e que a maconha e a cocaína são de sua propriedade, assim como o crack que estava em posse do menor. O depoente não o conhecia dos meios policiais; ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Piracicaba

Foro de Piracicaba

2ª Vara Criminal

Rua Bernardino de Campos, 55, Sala 05/07, Alemães - CEP 13417-100, Fone: (19)3433-4177, Piracicaba-SP - E-mail: piracicaba2cr@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO, DEBATES E JULGAMENTO

Processo Digital nº:

1501471-91.2021.8.26.0599

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2262034/2021 - 02º D.P.

PIRACICABA, 20468690 - 02º D.P. PIRACICABA, 3698/21/518 - 02º D.P. PIRACICABA, 2262034 - 02º D.P. PIRACICABA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

FELIPE AUGUSTO DE OLIVEIRA

Vítima:

SAÚDE PÚBLICA

Artigo da Denúncia:

*

Réu Preso

Tramitação prioritária

Aos 26 dias do mês de janeiro de 2022, à hora designada, por meio da Ferramenta Microsoft Teams, nos termos do Comunicado CG 284/2020, apresentaram-se a Exma. Sra. Dra. FLAVIA DE CASSIA GONZALES DE OLIVEIRA, MMª Juíza de Direito, o representante do Ministério Público, Dr. Denis Peixoto Parron e o(a) Defensor(a) Público(a), Dr(a).Daniela Batalha Trettel. Apresentados o(a)(s) acusado(a)(s) FELIPE AUGUSTO DE OLIVEIRA, e as testemunhas arroladas em comum pelas partes: Francisco Dernival Miranda Júnior, Felipe Vieira Alves.

Ausente a testemunha arrolada em comum pelas partes Ygor Fernando França Almeida. Fica consignado que foi assegurado o direito de entrevista do(a)(s) acusado(a)(s) com seu(sua)(s) defensor(a)(es), em reunião virtual apartada, no estrito cumprimento do artigo 185, § 5º, do C.P.P., tendo a MM Juíza feito ao(a)(s) acusado(a)(s) a observação determinada no artigo 186 do Código de Processo Penal. INICIADOS OS TRABALHOS, com a concordância das partes, pela MM. Juíza foi(ram)

colhido(s) o(s) depoimento(s) da(s) testemunha(s) (Francisco) pelo sistema virtual e, em seguida, interrogado(a)(s) o(a)(s) réu(ré)(s).

Pelas partes foi dito que desistem da oitiva das testemunhas Felipe e Ygor.

Em seguida, pela MM Juíza foi deliberado:

Homologo a desistência das partes em relação às testemunhas Felipe Vieira Alves e Ygor Fernando França Almeida.

"Não havendo mais provas a serem produzidas, encerro a instrução, determinando às partes que passem aos debates orais:

Dada a palavra ao(à) ilustre representante do Ministério Público, manifestou-se sua Excelência nos seguintes termos:

"MM. Juíza,

FELIPE AUGUSTO DE OLIVEIRA foi denunciado e está sendo processado pela prática do delito descrito no art. 33, caput, combinado com o artigo 40, inciso VI, da Lei nº 11.343/06, porque, no dia 24 de setembro de 2021, por volta de 10h38m, na rua Senador Saraiva, nº 1.102, bairro Monte Líbano, nesta cidade e comarca, agindo em concurso e unidade de desígnios com o adolescente Ygor Fernando França Almeida, trazia consigo 44 eppendorf's de cocaína, 70 porções de maconha e 128 porções de "crack", destinadas à mercancia ilícita ou entrega de qualquer forma a consumo de terceiras pessoas, substâncias entorpecentes que determinam dependência física ou psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, além da quantia de R\$ 142,00 (cento e quarenta e dois reais) em espécie.

Os fatos imputados na exordial acusatória foram comprovados ao longo da instrução criminal, pelo que a ação é procedente.

A materialidade foi comprovada através do boletim de ocorrência (fls. 08/10), auto de exibição e apreensão (fls. 11/12) e Laudo definitivo de exame químico-toxicológico (fls. 151/153).

A autoria, da mesma forma, é indubitosa.

Segundo se apurou, guardas municipais, em patrulhamento, avistaram o denunciado e o adolescentes parados no local dos fatos e perceberem que eles iniciaram fuga assim que avistaram a viatura. No entanto, durante a evasão, ambos caíram ao chão e foram detidos.

Feita abordagem de praxe, em poder do denunciado foram encontrados 44 eppendorf's de cocaína, 70 porções de maconha e a quantia R\$ 89,00. Em poder do adolescente Ygor, foram localizadas 128 porções de "crack" e o valor de R\$ 53,00.

Perante a autoridade policial, o adolescente declarou que estava vendendo droga para o denunciado e que ganharia R\$ 20,00 por cada mula vendida (26 porções de "crack")- fls. 05.

Por sua vez, o denunciado permaneceu em silêncio (fls. 06/07).

Diante das circunstâncias apuradas, apreensão de significativa quantidade de substância entorpecente em porções individualizadas, apreensão de dinheiro e declaração formal do adolescente, infere-se que as drogas destinavam-se à mercancia ilícita ou entrega de qualquer forma a consumo de terceiras pessoas.

A testemunha Francisco Dernival, guarda civil, disse "é Guarda Civil Municipal e na data de hoje estava em patrulhamento preventivo pelo Bairro Itapuã, quando avistaram dois indivíduos parados, no interior da favela, em uma das vielas, contudo, ao verem a viatura empreenderam fuga, correndo, sendo que um deles caiu e o segundo também, pois ali se trata de uma descida com rua em terra, com pedregulhos, ambos sofreram apenas poucas escoriações. Foram capturados. Em revista pessoal foram identificados como sendo, o maior de nome FELIPE AUGUSTO DE OLIVEIRA, e o menor YGOR FERNANDO FRANÇA ALMEIDA, MENOR DE 16ANOS, sendo que com Felipe foram localizados 44 eppendorf's de cocaína e 70 porções de maconha e R\$89,00, em uma pochete a tira colo. Com Ygor, foram localizados 128 porções de crack e R\$ 53,00 nos bolsos do moletom que trajava. Questionado, Ygor confessou que era seu primeiro dia no tráfico, e ganharia\$ 20,00 por cada mula vendida (que são 26 unidades de crack) e cada pedra, estava sendo vendida por R\$5,00. Quanto a Felipe, confessou que tem condenações por tráfico e que a maconha e a cocaína são de sua propriedade, assim como o crack que estava em posse do menor. O depoente não o conhecia dos meios policiais; foi necessária a utilização de algemas por fundado receio de nova fuga. A genitora do menor foi localizada e compareceu ao distrito, assim como a

esposa de Felipe acompanhou sua prisão no local, chegando a quase desmaiar, mas foi socorrida pelo depoente e permaneceu no local dos fatos, cientificada da prisão, comparecendo ao distrito" (fls. 02).

EM JUÍZO, reforçou essas assertivas. Passou pelo local, já conhecido como ponto de trafico, e viu duas pessoas conversando. Essas pessoas correram para a favela quando viram a viatura. Perseguiu-os e abordou FELIPE. Encontrou 44 porcoes de cocaína e 70 de maconha, além de dinheiro, com ele. O colega de farda continuou na busca da segunda pessoa e a abordou. Era o adolescente IGOR, com quem apreenderam 128 porções de crack e dinheiro. Ambos confirmaram as drogas com destino ao tráfico.

A testemunha Felipe Vieira Alves asseverou "é Guarda Civil Municipal e na data de hoje estava em patrulhamento preventivo pelo Bairro Itapuã, juntamente com seu colega de farda GC Miranda, quando avistaram dois indivíduos parados, em uma das vielas, contudo, ao verem a viatura empreenderam fuga, correndo, e escorregaram os pedregulhos, mas ambos sofreram apenas poucas escoriações. Foram capturados. Em revista pessoal foram identificados como sendo, o maior de nome FELIPE AUGUSTO DEOLIVEIRA, e o menor YGOR FERNANDO FRANÇA ALMEIDA, MENOR DE 16 ANOS, sendo que com Felipe foram localizados 44 eppendorfs de cocaína e 70 porções de maconha e R\$ 89,00, em uma pochete tira colo. Com Ygor, foram localizados 128 porções de crack e R\$ 53,00 nos bolsos do moletom que trajava. Questionado, Ygor confessou que era seu primeiro dia no tráfico, e ganharia R\$ 20,00 por cada mula vendida (que são 26 unidades de crack) e cada pedra, estava sendo vendida por R\$ 5,00, por isso tinha dinheiro no bolso. Quanto a Felipe, confessou que tem condenações por tráfico e que a maconha e cocaína são de sua propriedade, assim como o crack que estava em posse do menor. O depoente não o conhecia dos meios policiais; foi necessária a utilização de algemas por fundado receio de nova fuga. A genitora do menor, de nome Daiane, foi localizada e compareceu ao distrito, assim como a esposa de Felipe acompanhou sua prisão no local, chegando a quase desmaiar, mas foi socorrida pelo depoente e permaneceu no local dos fatos, cientificada da prisão, comparecendo ao distrito" (fls. 04).

Ouvido, o adolescente Ygor Fernando França declarou "na data de hoje estava vendendo drogas para Felipe, e que o conhece a pouco tempo, mas ele prometeu lhe pagar R\$ 20,00 por cada "mula" que contém 26 unidades cada uma. Ou seja, cada pedra foi vendida por R\$ 5,00 e por este motivo ele estava com dinheiro no bolso da blusa. Afirmou que está arrependido. Ao avistar a viatura correu e acabou caindo e ralou os joelhos, mas compareceu ao Ps Vila Cristina por praxe" (fls. 05).

Perante a autoridade policial o réu permaneceu em silêncio (fls. 06/07).

INTERROGADO EM JUÍZO, confessou os fatos. Disse que eram duas biqueiras, uma em cada viela. Trabalha em uma e o adolescente em outra. O adolescente correu e gritou "molhou". Correu também e foi perseguido. Os agentes atiraram. Parou e permitiu-se ser preso. Portava cocaína, maconha e dinheiro. Com o adolescente, tinha o crack. Não deu essa droga ao menor. Vende apenas cocaína e maconha. O dinheiro era da venda da droga.

Diante do todo apurado há provas suficientes que demonstram que o réu foi autor do delito em questão.

A narrativa dos guardas foi firme e uníssona em confirmar que avistam o réu juntamente com o adolescente parados na via pública, os quais, ao perceberem a aproximação da viatura, empreenderam fuga. Feita a abordagem de praxe, com ambos foram localizadas drogas. Instado, o réu confessou a propriedade do entorpecente. Outrossim, o adolescente declarou que realizada a mercancia ilícita para o réu. Assim, inequívoco que o réu foi autor do delito, tendo em vista as circunstancias apuradas, significativa quantidade de droga apreendida e localização de dinheiro. Os policiais não conheciam o réu e nada tinham contra ele. Pertinente salientar, que não há nada que invalide os depoimentos dos guardas civis, devendo ser valorados como as demais provas constantes no processo.

Neste sentido:

APELAÇÃO. Tráfico de entorpecentes. Artigo 33, caput, da lei nº 11.343/06.

Materialidade e autoria devidamente comprovadas pelo conjunto probatório carreado aos autos. Valor do depoimento testemunhal de servidores policiais que, ratificados

em juízo, sob a garantia do contraditório, reveste-se de inquestionável eficácia probatória. Inexistência de contradições ou elementos de convicção que possam retirar-lhe a credibilidade. Dosimetria da pena mantida. Regime inicial fechado adequadamente imposto. Análise da detração que compete ao Juízo das Execuções Criminais. RECURSO DESPROVIDO. (Apelação nº 3005429- 53.2013.8.26.0320, 15ª Câmara de Direito Criminal, Rel. Camargo Aranha Filho, j .05/05/2016) – Grifo nosso. Ademais, o adolescente declarou que a droga pertencia ao réu e que ele lhe pagaria o valor de R\$ 20,00 para que ele realizasse a venda do entorpecente.

Destarte, diante do conjunto probatório imperiosa a condenação do réu pelo delito em questão.

Passo a analisar a dosimetria da pena.

A reincidência específica dele fará com que sua pena seja agravada. Confissão como circunstância atenuante.

A prova acostada e declarações do adolescente deixaram claro que o réu envolveu o menor em sua conduta, o que fará com que a pena seja majorada (art. 40, inciso VI, Lei 11.343/06).

A quantidade de entorpecente apreendida e localização de dinheiro em poder do réu deixa clara sua dedicação ao crime de tráfico ilícito de drogas, razão pela qual deve ser afastada a benesse prevista no artigo 33, §4º, da Lei de Drogas.

Outrossim, o réu é reincidente específico.

Tratando-se de delito assemelhado ao hediondo e tendo-se em conta a necessidade de se individualizar a pena para a adequada prevenção e reprovação, incabível substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, devendo o réu iniciar o desconto da pena no regime inicial fechado.

Destarte, requer seja julgada procedente a ação penal e o réu condenado nos exatos termos da inicial.

Dada a palavra ao(à) nobre defensor(a) do(a)(s) acusado(a)(s), manifestando-se sua Excelência nos seguintes termos:

"MM.Juíza,

Felipe Augusto de Oliveira foi denunciado como incurso no artigo 33, caput, combinado com o artigo 40, inciso VI, da Lei nº 11.343/06.

Segundo a denúncia (fls. 118-120), no dia 24 de setembro de 2021, por volta de 10h38, na rua Senador Saraiva, nº 1.102, bairro Monte Líbano, nesta cidade e comarca de Piracicaba/SP, Felipe, agindo em concurso e unidade de desígnios com o adolescente Ygor Fernando França Almeida, trazia consigo 44 eppendorff's de cocaína, 70 porções de maconha e 128 porções de "crack", destinadas à mercancia ilícita ou entrega de qualquer forma a consumo de terceiras pessoas, além da quantia de R\$ 142,00 (cento e quarenta e dois reais) em espécie.

Ainda de acordo com a inicial, guardas municipais, em patrulhamento, avistaram o réu e o adolescente parados no local dos fatos e perceberem que eles iniciaram fuga assim que avistaram a viatura. No entanto, durante a evasão, ambos caíram ao chão e foram detidos. Feita abordagem de praxe, em poder do réu foram encontrados 44 eppendorff's de cocaína, 70 porções de maconha e a quantia R\$ 89,00. Em poder do adolescente Ygor, foram localizadas 128 porções de "crack" e o valor de R\$ 53,00. Interrogado em solo policial, o réu exerceu o seu direito constitucional ao silêncio (fls. 6-7).

Francisco Dernival Miranda Junior, guarda civil, narrou que: "na data de hoje, estava em patrulhamento preventivo pelo bairro Itapuã, quando avistaram dois indivíduos parados, no interior da favela, em uma das vielas, contudo, ao verem a viatura empreenderam fuga, correndo, sendo que um deles caiu e o segundo também, pois ali se trata de uma descida com rua em terra, com pedregulhos, ambos sofreram apenas poucas escoriações. Foram capturados. Em revista pessoal foram identificados como sendo, o maior de nome Felipe Augusto de Oliveira e o menor Ygor Fernando França Almeida, menor de 16 anos. Com Felipe foram localizados 44 eppendorff's de cocaína e 70 porções de maconha e R\$ 89,00, em uma pochete a tira colo. Com Ygor, foram localizadas 128 porções de crack e R\$ 53,00 nos bolsos do moletom que trajava. Questionado, Ygor confessou que era seu primeiro dia no tráfico e ganharia R\$ 20,00 por cada mula vendida (que são 26 unidades de crack) e cada pedra, estava sendo vendida por R\$ 5,00. Quanto a Felipe, confessou que tem condenações por

tráfico e que a maconha e a cocaína são de sua propriedade, assim como o crack que estava em posse do menor. Não o conhecia dos meios policiais. Foi necessária a utilização de algemas por fundado receio de nova fuga. A genitora do menor foi localizada e compareceu ao distrito, assim como a esposa de Felipe acompanhou sua prisão no local, chegando a quase desmaiar, mas foi socorrida pelo depoente e permaneceu no local dos fatos, cientificada da prisão, comparecendo ao distrito" (fls. 2-3).

No mesmo sentido a versão apresentada pelo guarda municipal Felipe Vieira Alves (fls. 4).

Ygor Fernando França Almeida, adolescente, relatou, em solo policial, que: "na data de hoje, estava vendendo drogas para Felipe, que conheceu a pouco tempo, mas ele lhe prometeu pagar R\$ 20,00 por cada "mula" que contém 26 unidades cada uma. Ou seja, cada pedra foi vendida por R\$ 5,00 e por este motivo ele estava com dinheiro no bolso da blusa. Está arrependido. Ao avistar a viatura correu e acabou caindo e ralou os joelhos, mas compareceu ao Ps Vila Cristina por praxe" (fls. 5).

Às fls. 51-54, juntada certidão de objeto e pé que indica a reincidência do requerido (autos n.º 0011503-06.2019.8.26.0502 - tráfico - trânsito em julgado para a Defesa em 17/12/2020).

- DA PRODUÇÃO DE PROVAS NOS AUTOS

A materialidade do delito se comprova pelo auto de exibição e apreensão de fls. 11-12, fotografia de fls. 15, laudo de constatação de fls. 16-21, laudo de exame definitivo de fls. 151-153.

Com relação à autoria, em audiência de instrução foram colhidos os seguintes elementos:

a) Ouvido, inicialmente, Francisco Dernival Miranda Junior, guarda municipal. Relatou que passava pelo local no dia dos fatos, que é conhecido como ponto de drogas. Visualizaram dois indivíduos conversando, na entrada da comunidade. Quando os indivíduos viram a viatura, saíram correndo em direção à comunidade, entrando em vielas. Seguiram ambos a pé. Felipe caiu. Mirando o deteve e, em busca pessoal, encontrou 44 porções de cocaína, 70 de maconha e dinheiro (R\$89,00), tudo em uma pochete. O parceiro continuou acompanhando Ygor e logo voltou com o adolescente, que tinha em sua posse dinheiro (R\$53,00) e 128 porções de crack. Explicou que os indivíduos caíram porque o terreno era desnivelado e com pedregulhos; por isso escorregaram e caíram ao correr. Estavam de chinelos, mas não tem certeza. Em entrevista informal, Felipe assumiu que estava traficando e tinha convidado Ygor para lhe ajudar, incumbindo-o de vender o crack. Ygor confirmou essa informação, disse que ganharia R\$20,00 por cada "mula" vendida. Não conhecia Felipe ou Ygor.

b) Por fim, foi interrogado o réu Felipe Augusto de Oliveira. Contou que havia duas biqueiras no local. Há uma biqueira em cada viela. Ygor viu o policial vindo e gritou "moio". Saiu correndo, o policial deu um tiro, caiu. Levantou-se e o policial deu mais dois tiros. Desistiu de fugir e foi preso. O Ygor correu para outra viela, em outra direção. Estava com a cocaína, a maconha e o dinheiro apreendidos. Ygor estava com o crack. Não tinha dado o crack para Ygor vender, pois só vende "pó" e maconha. O dinheiro era da venda da droga. Os policiais o levaram para a sua casa, não tinha nada ali, tinha uma balança que era usada pela esposa, que vende doces, e eles viram os doces e que não era balança do tráfico. É usuário de maconha, mas consegue ficar sem. Não conhece os guardas e não tem nada contra.

- DA ILICITUDE PROBATÓRIA: INCONSTITUCIONAL E ILEGAL ATUAÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL

Inicialmente, deve ser reconhecida a ilicitude probatória, tendo em vista a atuação inconstitucional e ilegal da Guarda Municipal. Não bastasse, a atuação da GCM em atividade de policiamento ostensivo e investigativo, por si só, também é ilícita. Dessa maneira, a busca pessoal que resultou na apreensão das drogas foi oriunda de atuação da Guarda Civil Municipal.

Ocorre que, nos termos da Constituição Federal, art. 144, § 8º, a Guarda Municipal não tem competência para tanto. É no mesmo sentido a lição doutrinária (GASPARINI, Diógenes; As guardas municipais na constituição federal de 1988, Revista dos Tribunais. set./1991. v.671 p. 46-53; SILVA, José Afonso da. Comentário Contextual à Constituição, 3. ed. São Paulo: Malheiros, 2007, p. 638-9).

Por conseguinte, é inafastável a conclusão de que a apreensão dos entorpecentes,

por guardas municipais, é medida ilícita, tornando imprestáveis, portanto, os elementos de prova daí decorrentes.

Em reforço, não há que se alegar que os guardas municipais teriam atuado legitimamente porquanto, nos termos do art. 301 do Código de Processo Penal, seria facultado a qualquer do povo efetuar a prisão em flagrante. In casu, não há que se falar em flagrante porquanto não houve qualquer motivação legítima para proceder à abordagem, eis que, conforme relatado pelas guardas municipais, logo após a visualização do imputado, elas efetuaram a abordagem imediatamente por considerarem que, ao visualizar a viatura, o réu e o menor “empreenderam fuga”. Os guardas sequer visualizaram a prática de qualquer atividade relacionada ao tráfico. O averiguado, portanto, não estava em situação de flagrância.

E, ainda que superado esse argumento, considerando-se legítima a prisão em flagrante, é certo que os guardas municipais carecem de competência para efetuar a busca pessoal, atividade típica de policiamento, vez que esta não é um desdobramento automático e necessário do flagrante. Tanto que a prisão em flagrante e a busca e apreensão são disciplinadas em seções autônomas do Código de Processo Penal, sendo que a busca pessoal somente será realizada quando houver “fundada suspeita” (CPP, art. 240, § 1º); enquanto a busca pessoal é uma medida de obtenção de prova, a prisão em flagrante é um ato pré-cautelar.

Ademais, o art. 241 c. c/ art. 244, ambos do Código de Processo Penal, estabelecem que a busca pessoal será conduzida pela autoridade policial. Assim, ainda que as guardas municipais, em razão do disposto no art. 144 da Constituição Federal, integrem a segurança pública, é certo que não podem ser considerados “autoridades policiais”; não por outra razão, quando efetuam a prisão em flagrante, fazem-no como “qualquer do povo”, com fundamento na parte inicial do art. 301 do Código de Processo Penal. Logo, para fins do art. 241 c. c/ art. 244, ambos do Código de Processo Penal, os guardas municipais não se equiparam às autoridades policiais. Assim, deparando-se com uma hipótese de flagrante, os guardas municipais devem apenas efetuar a custódia do indivíduo, encaminhando-o às autoridades policiais, sendo-lhes defeso efetuar a revista pessoal do cidadão detido.

Para melhor ilustrar, cite-se o habeas corpus n. 470.937-SP, em que o Superior Tribunal de Justiça considerou ilícita a revista pessoal efetuada por agente de segurança privada. Extraí-se do referido julgado, aplicável ao presente caso por analogia, que, tal como os seguranças privados, os guardas municipais poderiam ter efetuado a custódia do indivíduo, atuando como “qualquer do povo” (CPP, art. 301), mas não a sua revista pessoal (HC 470.937-SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, por unanimidade, julgado em 04/06/2019, DJe 17/06/2019).

Em síntese, atuando como “qualquer do povo”, os guardas municipais podem, única e exclusivamente, efetuar a custódia de algum cidadão que esteja em situação de flagrante (CPP, art. 301), mas não podem efetuar a busca pessoal ou desenvolver atividades tendentes à obtenção de elementos de informação, sob pena de afronta ao disposto no art. 241 c. c/ art. 244, ambos do Código de Processo Penal, eis que, para esses fins, a despeito de estarem encarregados da segurança pública (CF, art. 144), não são considerados “autoridades policiais”. Nesse sentido, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça: (STJ, Habeas corpus 545.162/SP, Rel. Nefi Cordeiro, julgado em 4/2/2020).

Assim, tem-se que a apreensão das drogas, no caso sub examine, é elemento de prova ilícito, tendo em vista a inconstitucional atuação da Guarda Municipal. Por esse motivo, o auto de apreensão das drogas deverá ser desentranhado dos autos, eis que é inadmissível o seu ingresso no processo (CF, art. 5º, LVI c. c/ CPP, art. 157). E, por via de consequência, o laudo de constatação e o laudo de exame químico-toxicológico são provas ilícitas por derivação, não podendo servir para formação da convicção judicial, vale dizer, mostram-se incapazes para atestar a materialidade do delito imputado ao denunciado.

Desse modo, a absolvição, nos termos do art. 386, V, do CPP, é medida que se impõe.

- DAS ALEGAÇÕES RELATIVAS À DOSIMETRIA DA PENA

No mais, caso superada a preliminar, a defesa passa a se manifestar acerca da pena

a) Da pena-base

Na remota hipótese de condenação, de rigor a fixação da pena-base em seu mínimo

legal: as consequências e a culpabilidade são normais para o caso, não justificando uma reprovação penal maior.

No mais, as condenações anteriores devem ser avaliadas na segunda fase de fixação de pena, sob pena de bis in idem.

b) Da segunda fase da dosimetria

Na segunda fase, há a reincidência do réu, permitindo o aumento da pena em 1/6, que deverá ser compensada com a atenuante da confissão, mantendo-se a pena no mínimo legal.

c) Da causa de aumento do artigo 40, inciso VI da LD

No que diz respeito ao envolvimento de menor na prática delitiva, de rigor o seu afastamento, posto que não demonstrado nos autos o liame subjetivo entre o réu e a suposta outra pessoa que teria participado da conduta. O réu explicou que, embora presos conjuntamente, o adolescente trabalhava em outro ponto de venda de drogas, no qual se comercializa crack, enquanto Ygor vendia crack na “boca” que comercializa esse produto.

- DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA

No que tange ao regime inicial, não aplicável ao caso o regime fechado. Em atenção ao disposto no art. 33, § 3º, diante da quantidade pena a ser aplicada e das circunstanciais judiciais, inexistindo fundamentação concreta a recomendar o regime mais gravoso (Súmulas 718 e 719 do STF; Súmula 440 do STJ), de rigor a aplicação do regime diverso do fechado.

Adicionalmente, para a fixação do regime inicial, não poderá ser observado o disposto no art. 1º, § 2º, da LCH, tendo em vista que a declaração de inconstitucionalidade pelo STF, exercendo sua função típica de guardião da Constituição e, por isso, proferindo uma decisão de observância obrigatória por todo o Judiciário (CF, art. 102 c. c/ art. 927 do CPC).

- DO DIREITO DE APELAR EM LIBERDADE

Finalmente, deve ser assegurado ao acusado o direito de apelar em liberdade. De acordo com o art. 387, § 1º, do Código de Processo Penal, ao proferir uma sentença de condenação, “O juiz decidirá, fundamentadamente, sobre a manutenção ou, se for o caso, a imposição de prisão preventiva ou de outra medida cautelar, sem prejuízo do conhecimento de apelação que vier a ser interposta”. Ademais, a decisão pela manutenção da prisão preventiva deve ser concreta, cabendo ao julgador “[...] indicar concretamente a existência de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada” (CPP, art. 315, § 2º). Com efeito, uma vez encerrada a instrução, ainda que se entenda pela manutenção da prisão preventiva anteriormente exposta, a decisão deve ser concretamente fundamentada, visto que ainda vigente o estado de inocência (CF, art. 5º, LVII; CADH, art. 8.2).

No mais, no atual cenário, qualquer decisão que determina o recolhimento de alguém ao cárcere ou a manutenção de uma prisão anteriormente decretada deve ser ponderada à luz da crise sanitária causada pelo COVID-19. Considerando a situação emergencial de saúde pública decorrente do coronavírus (COVID-19), somada ao fato de que estabelecimentos em que há aglomeração de pessoas privadas de liberdade são muito mais suscetíveis à disseminação de doenças virais, e visando a reduzir ao máximo os riscos advindos de uma possível contaminação por coronavírus, principalmente dos sujeitos ainda protegidos pela presunção de inocência e acusados de crime não considerados graves, mostra-se imperiosa a concessão do direito de apelar em liberdade, caso o acusado seja condenado.

Em seguida pelo(a) MM.Juiz(a) foi dito o seguinte:

Passo a proferir a seguinte sentença:

VISTOS.

FELIPE AUGUSTO DE OLIVEIRA, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso nas penas do artigo 33, caput, e artigo 40, inciso VI, ambos da Lei nº 11.343/06, porque no dia 24 de setembro de 2021, por volta de 10h38, na rua Senador Saraiva, nº 1.102, bairro Monte Líbano, nesta cidade e comarca, agindo em concurso e unidade de desígnios com o adolescente Y.F.F.A., trazia consigo 44 eppendorf's de cocaína, 70 porções de maconha e 128 porções de “crack”, destinadas à mercancia ilícita ou entrega de qualquer forma a consumo de terceiras pessoas, substâncias entorpecentes que determinam dependência física ou psíquica, sem autorização e em desacordo com

determinação legal e regulamentar, além da quantia de R\$ 142,00 (cento e quarenta e dois reais) em espécie.

Segundo a denúncia, guardas municipais, em patrulhamento, avistaram o réu e o adolescente parados no local dos fatos e perceberem que eles iniciaram fuga assim que avistaram a viatura. No entanto, durante a evasão, ambos caíram ao chão e foram detidos.

Feita abordagem de praxe, em poder do réu foram encontrados 44 eppendorf's de cocaína, 70 porções de maconha e a quantia R\$ 89,00. Em poder do adolescente Y., foram localizadas 128 porções de "crack" e o valor de R\$ 53,00.

Perante a autoridade policial, o adolescente declarou que estava vendendo droga para o réu e que ganharia R\$ 20,00 por cada mula vendida (26 porções de "crack") - fls. 05.

Por sua vez, o réu permaneceu em silêncio (fls. 06/07)

Diante das circunstâncias apuradas, apreensão de significativa quantidade de substância entorpecente em porções individualizadas, apreensão de dinheiro e declaração formal do adolescente, infere-se que as drogas se destinavam à mercancia ilícita ou entrega de qualquer forma a consumo de terceiras pessoas.

A denúncia foi oferecida sem oferecimento de acordo de não persecução penal (fls. 117), sendo determinada a notificação do réu para oferecer defesa prévia, nos termos do artigo 55 da Lei nº 11.343/06 (fls. 121/122).

O réu foi notificado (fls. 131), apresentando defesa prévia, na qual requereu a revogação da prisão preventiva e alegou inocência (fls. 135/138).

A denúncia foi recebida, mantendo-se a prisão cautelar (fls. 154/157). O réu foi citado (fls. 177).

Em audiência, foi ouvida 01 testemunha comum, sendo o réu interrogado.

Encerrada a instrução, em memoriais, as partes se manifestaram.

É o relatório.

DECIDO.

I - Da Preliminar

Pleiteia a Defesa, o reconhecimento da nulidade do processo, em razão da prisão realizada por guardas municipais. Argumenta que houve diligência típica de atividade policial, não permitida aos guardas municipais.

Não há, contudo, qualquer nulidade na prisão em flagrante do réu.

Não se verifica qualquer abuso ou ilegalidade na diligência efetuada pelos guardas municipais que perseguiram o réu e o adolescente, que estavam em ponto de venda de drogas, após eles terem corrido, assim que avistaram a viatura.

Por fim, a Lei nº 13.022/14 conferiu expressamente à Guarda Municipal a atribuição de polícia ostensiva, nos termos do artigo 3º da referida legislação, que assim dispõe: "Artigo 3º. São princípios mínimos de atuação das guardas municipais: I - proteção dos direitos humanos fundamentais, do exercício da cidadania e das liberdades públicas; II - preservação da vida, redução do sofrimento e diminuição das perdas; III - patrulhamento preventivo; IV - compromisso com a evolução social da comunidade; e V - uso progressivo da força".

De qualquer modo, nada obstante o disposto no artigo 144, parágrafo 8º, da Constituição Federal, é certo que, à luz do artigo 301 do Código de Processo Penal, não há uma proibição de que os guardas municipais prendam alguém em flagrante, haja vista que qualquer pessoa do povo também pode fazê-lo.

E, no caso concreto, ao contrário do postulado pela Defesa, o réu foi abordado na posse da droga apreendida, logo após fugir de eventual abordagem, estando em ponto de venda de drogas, havendo flagrante, consoante prevê o artigo 302, inciso IV, do Código de Processo Penal.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça:

É assente nesta Corte Superior de Justiça a orientação de que os integrantes da guarda municipal não desempenham a função de policiamento ostensivo; todavia, em situações de flagrante delito, como restou evidenciado ser o caso, a atuação dos agentes municipais está respaldada no comando legal do art. 301 do Código de Processo Penal - CPP.[...] 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n.º

603.686/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 9/2/2021, DJe 17/2/2021) Ante o exposto, não conheço o presente habeas corpus. Intimem-se.

Brasília, 25 de junho de 2021. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA Relator. (STJ - HC: 676532 SP 2021/0199414-0, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Publicação: DJ 29/06/2021).

"O recurso comporta parcial provimento. No caso, quanto à prisão em flagrante realizada por guardas municipais, inexistente ofensa aos alegados dispositivos de lei federal, pois o entendimento do Tribunal de origem alinha-se à jurisprudência desta Corte consolidada no sentido de que, "apesar das atribuições previstas no art. 144, § 8º, da Constituição Federal, se qualquer pessoa do povo pode prender quem quer que esteja em situação de flagrância, não se pode proibir o guarda municipal de efetuar tal prisão" (HC n. 286.546/SP, relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta Turma, julgado em 22/9/2015, DJe de 15/10/2015). Nesse sentido, confira-se ainda: HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. INVASÃO DE DOMICÍLIO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DAS PROVAS. CRIME PERMANENTE. FLAGRANTE DELITO. FUNDADAS RAZÕES. ATUAÇÃO DE GUARDAS MUNICIPAIS. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. [...] 4. "É assente nesta Corte Superior de Justiça a orientação de que os integrantes da guarda municipal não desempenham a função de policiamento ostensivo; todavia, em situações de flagrante delito, como restou evidenciado ser o caso, a atuação dos agentes municipais está respaldada no comando legal do art. 301 do Código de Processo Penal" (HC 471.229/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 19/2/2019, DJe 1º/3/2019) 5. Habeas Corpus não conhecido. (HC 525.772/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 17/10/2019, DJe 24/10/2019). Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso especial para, na segunda fase da dosimetria, compensar integralmente a agravante de reincidência com a atenuante de confissão, fixando a pena definitiva do paciente em 3 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial fechado, mais 11 dias-multa. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 24 de junho de 2021. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Relator (STJ - Resp: 1940142 SP 2021/0159530-8, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Publicação: DJ 28/06/2021).

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO E USO DE DOCUMENTO FALSO. PRISÃO FLAGRANCIAL ILEGAL. GUARDA MUNICIPAL PODE PROMOVER PRISÃO EM FLAGRANTE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A primeira parte do art. 301 do Código de Processo Penal autoriza a qualquer do povo prender quem quer que seja encontrado em flagrante delito. Desse modo, inexistente ilegalidade na prisão em flagrante realizada por guardas municipais. 2. Conforme compreensão da Sexta Turma desta Corte Superior, havendo fundada suspeita a configurar situação de flagrante delito, mostra-se lícita a abordagem pessoal feita pela Guarda Civil Municipal, que não atua, nessa hipótese, como polícia investigativa. 3. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC: 667413 SP 2021/0152075-9, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 01/06/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/06/2021)

Nesse sentido também o Tribunal de Justiça de São Paulo:

PRELIMINAR. ILICITUDE DAS PROVAS. BUSCA PESSOAL REALIZADA POR GUARDAS CIVIS MUNICIPAIS. FALTA DE COMPETÊNCIA PARA O ATO. INEXISTÊNCIA. O Estatuto das Guardas Municipais (Lei nº 13.022/14), regulamentou o artigo 144, § 8º, da Constituição Federal, estabelecendo que compete à Guarda Civil Metropolitana, entre outras atribuições, prevenir, inibir e coibir infrações penais, bem como encaminhar indivíduos em flagrante delito à autoridade policial (art. 5º, II, III e IV da referida Lei). Ademais, como qualquer do povo, esses servidores podem efetuar a prisão em flagrante do agente cuja conduta se amolde às hipóteses taxativas do artigo 302 do Código de Processo Penal. Guardas civis municipais que foram alertados por transeunte sobre a conduta do réu, dirigiram-se ao local, observaram a prática de atos típicos de traficância e efetuarão sua prisão em flagrante delito. Ausência de ilicitude da busca pessoal que culminou na apreensão das drogas e dinheiro e o início da persecução penal. Preliminar rejeitada. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. CONDENAÇÃO MANTIDA. Materialidade e autoria bem demonstradas nos autos. Guardas civis, após denúncia de traficância, avistaram o réu Yan em movimentação típica de tráfico com dois indivíduos e o surpreenderam na posse de duas porções de cocaína, vindo a

localizar, no local de onde empreendera fuga, outras cinco porções da mesma droga, idênticas, e R\$ 20,00. Silente na fase extrajudicial, apelante negou em juízo o tráfico de drogas. Negativa e versão judiciais, além de fantasiosas e inverossímeis, sucumbiram à prova produzida pela Acusação. Condenação mantida. PENAS. Base fixada no mínimo legal. Pleito ministerial atendido para reconhecer-se a agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea "j", do Código Penal, haja vista a prática do crime durante o estado de calamidade pública da pandemia de COVID-19, mormente no caso dos autos, em que se apura crime que visa a resguardar a saúde pública. Mantido o reconhecimento da reincidência. Negada a aplicação do redutor, por vedação legal expressa. Pena majorada. REGIME PRISIONAL. Regime inicial fechado mantido, ante a quantidade de pena aplicada e a reincidência específica, além da gravidade concreta do delito praticado. Regime inicial fechado mantido. BENEFÍCIOS LEGAIS. Incabíveis o sursis penal e a substituição da pena corporal por restritiva de direitos, ante a quantidade de pena corporal (superior a quatro anos) e a reincidência específica do réu. Preliminar rejeitada e, no mérito, apelo defensivo desprovido, com provimento ao recurso ministerial para, reconhecida a agravante prevista no art. 61, II, "j", do Código Penal, redimensionar suas penas para 6 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa mínimos, com expedição de ofício de recomendação em seu desfavor. (TJ-SP - APR: 15015986320208260599 SP 1501598-63.2020.8.26.0599, Relator: Gilda Alves Barbosa Diodatti, Data de Julgamento: 29/06/2021, 15ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 29/06/2021 - grifei).

"Pondera-se, também, que em casos como o dos autos, por ser o tráfico de drogas um delito permanente, possível é a prisão flagrancial, a qualquer tempo e por qualquer um do povo, a teor do que dispõe o art. 301 do Código de Processo Penal. Destarte, não há impedimento legal para que membro da Guarda Civil Metropolitana efetue prisões em flagrante. Nesse sentido é a jurisprudência do col. Superior Tribunal de Justiça: HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. FLAGRANTE EFETUADO POR GUARDA MUNICIPAL. VALIDADE. ART. 312 DO CPP. PERICULUM LIBERTATIS. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. COVID-19. RECOMENDAÇÃO N. 62/2020 DO CNJ. INAPLICÁVEL. ORDEM DENEGADA. 1. Conforme já decidiu esta Corte Superior, é possível que, diante de notitia criminis, envolvendo qualquer dos bens jurídicos mencionados, o agente municipal proceda à atividade de vigilância no local indicado para se certificar de sua veracidade, hipóteses nas quais, de nenhum modo, estaria desautorizado a agir. 2. A situação de flagrância delitiva legitima a atuação de "qualquer pessoa do povo" a proceder à prisão, oportunidade em que é perfeitamente possível a realização da abordagem do suspeito, não sendo diferente em relação àqueles agentes que, ao realizarem seu mister de zelar pelo patrimônio público, muitas vezes se deparam com infrações penais, sendo-lhes lícito atuar em tais ocasiões. Precedentes. [...] 8. Ordem denegada. (HC 583.610/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 04/08/2020, DJe 14/08/2020). PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO CONFIRMADA PELO TRIBUNAL A QUO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. ALEGAÇÃO DE PROVA ILÍCITA. CONDUTA FLAGRADA POR GUARDAS MUNICIPAIS. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. [...] III - O reconhecimento de nulidades no curso do processo penal reclama uma efetiva demonstração do prejuízo à parte, sem a qual prevalecerá o princípio da instrumentalidade das formas positivado pelo art. 563 do CPP (pas de nullité sans grief). IV - Firme o entendimento jurisprudencial deste Superior Tribunal de Justiça no sentido de que: "Nos termos do artigo 301 do Código de Processo Penal, qualquer pessoa pode prender quem esteja em flagrante delito, razão pela qual não há qualquer óbice à sua realização por guardas municipais. Precedentes." (HC 357.725/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, DJe 12/5/2017). [...] Habeas corpus não conhecido. (HC 480.676/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 21/03/2019, DJe 28/03/2019). RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PRISÃO EM FLAGRANTE EFETUADA POR GUARDAS MUNICIPAIS. PROVAS ILÍCITAS. INOCORRÊNCIA. 1. Não há falar em ilegalidade da prisão em flagrante e, conseqüentemente, em prova ilícita, porque efetuada por guardas municipais, que estavam de ronda e foram informados da ocorrência da prática de tráfico de drogas na ocasião, se pode fazê-lo qualquer do povo (artigo 301 do Código de Processo

Penal). 2. Recurso improvido. (RHC 20.714/SP, Rel. Ministro HAMILTON CARVALHIDO, SEXTA TURMA, julgado em 10/05/2007, DJe 04/08/2008). (TJ-SP - RVCR: 22502921020198260000 SP 2250292-10.2019.8.26.0000, Relator: João Morengi, Data de Julgamento: 29/06/2021, 6º Grupo de Direito Criminal, Data de Publicação: 29/06/2021- grifei).

Apelação da Defesa – Tráfico de Drogas – Preliminar de nulidade – Ilegalidade da prisão, efetuada por guardas civis – Réus em situação de flagrância, cuja prisão pode ser efetuada por qualquer pessoa – Artigo 301 do CPP – Preliminar rejeitada – Provas suficientes à condenação – Materialidade e autoria comprovadas – Circunstâncias reveladoras do crime de tráfico de entorpecentes – Apreensão de significativa quantidade de maconha em poder dos acusados – Fator que, associado à prova produzida, leva à conclusão de que os entorpecentes eram destinados ao consumo de terceiros – Penas-base fixadas em seus patamares mínimos – Circunstância atenuante da menoridade relativa reconhecida, mas sem reflexo nas penas – Inaplicabilidade do redutor previsto no artigo 33, § 4º, da Lei Antidrogas – Redução que deve se voltar às hipóteses em que o acusado não faz da narcotraficância seu meio de vida – Regime inicial fechado mantido – Impossibilidade da fixação de regime aberto e da substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos – Mercês incompatíveis com delitos de singular gravidade – Necessidade de maior repressão ao tráfico de entorpecentes – Rejeitada a preliminar, recursos de apelação desprovidos. Apelação da Justiça Pública – Associação para o tráfico de drogas – Fragilidade do conjunto probatório – Circunstâncias que parecem indicar mero concurso eventual de agentes e não associação de cunho permanente – Absolvição mantida – Colaboração com o tráfico de drogas na condição de informante – Hipótese de coautoria – Ré que decidiu atuar na venda de drogas em comparsaria com sua companheira, havendo a divisão de tarefas e de lucros entre ambas – Crime subsidiário aplicável somente à colaboração eventual e desvinculada do efetivo comércio de entorpecentes – Condenação pelo crime do artigo 33, "caput", da Lei n. 11.343/2006 – Pena-base fixada em seu patamar mínimo – Circunstância atenuante da menoridade relativa reconhecida, mas sem reflexo na pena – Inaplicabilidade do redutor previsto no artigo 33, § 4º, da Lei Antidrogas – Redução que deve se voltar às hipóteses em que o acusado não faz da narcotraficância seu meio de vida – Regime inicial fechado – Impossibilidade da fixação de regime aberto e da substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos – Mercês incompatíveis com delitos de singular gravidade – Necessidade de maior repressão ao tráfico de entorpecentes – Recurso de apelação parcialmente provido. (TJ-SP - APR: 15029258520198260079 SP 1502925-85.2019.8.26.0079, Relator: Cesar Augusto Andrade de Castro, Data de Julgamento: 25/06/2021, 9ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 09/06/2021)

II – Do mérito

No mérito, a ação penal é procedente.

1) Da materialidade

A materialidade criminosa está consubstanciada no auto de exibição e apreensão de fls. 11/12, na fotografia de fls. 15, no laudo de constatação de fls. 16/21, bem como no laudo de exame químico-toxicológico de fls. 151/153, segundo o qual foram constatadas as presenças das substâncias cocaína e Tetrahydrocannabinol (THC), no material apreendido.

2) Da autoria

A autoria criminosa é certa e deve ser imputada ao réu.

Na fase investigativa, o réu permaneceu silente, apenas alegando que já foi condenado por tráfico outras vezes (fls. 06/07).

Em Juízo, o réu relatou que na verdade, no local existem duas “biqueiras”, uma em cada viela. Trabalhava em uma “biqueira” e ele trabalhava em outra. Quando os policiais apareceram, Ygor avisou que deveria correr. Começou a correr, mas o guarda saiu atrás dele. Quando começou a correr, o guarda civil disparou um tiro, suas pernas ficaram moles e caiu, ferindo-se. Levantou-se e continuou a fuga, mas o guarda desferiu mais dois disparos e acabou parando e sendo abordado. Y. correu em outra viela e foi detido em outro lugar. Consigo, havia cocaína e maconha e um pouco do dinheiro. Com Y., havia crack. Não tinha dado o crack para Y. vender. O

dinheiro era proveniente da venda de drogas. Os guardas foram até sua casa, mas não encontraram nada. Faz uso de maconha, mas consegue ficar sem consumi-la. Nada tem contra os guardas e o adolescente.

A autoria foi amparada pelas demais provas produzidas nos autos. Vejamos.

O guarda municipal Francisco Dernival Miranda Júnior referiu que estavam passando pelo local já conhecido como ponto de venda de drogas, quando visualizaram um próximo ao outro conversando, em uma das vielas da comunidade. Quando perceberam a presença dos guardas, eles saíram correndo, indo para o interior da favela.

Precisaram desembarcar da viatura, para acompanhá-los. Em dado momento, o réu acabou caindo e já conseguiu detê-lo. Em revista pessoal, encontrou 44 porções de cocaína, 70 porções de maconha e R\$ 89,00, dentro de uma pochete. Seu parceiro continuou acompanhando o outro indivíduo e, depois de certo tempo, retornou com o outro indivíduo, que também tinha caído e foi abordado. Tratava-se de Y., com que havia 128 porções de crack e R\$ 53,00. O local é bem desnivelado e tem bastante pedregulho, motivo pelo qual eles acabaram escorregando e caindo. Não sabe qual o calçado que eles usavam. O réu disse que estava ali para fins do comércio de drogas e tinha convidado o adolescente para que o ajudasse na venda, deixando que ele fizesse a venda aos usuários. O adolescente contou a mesma história, dizendo que iria ganhar R\$ 20,00 por cada mula vendida. Não conhecia o réu e o adolescente. Ouvido apenas na fase policial, o guarda municipal Felipe Vieira Alves narrou que, na data dos fatos, estava em patrulhamento preventivo pelo Bairro Itapuã, juntamente com seu colega de farda GC Miranda, quando avistaram dois indivíduos parados, em uma das vielas, contudo, ao verem a viatura eles empreenderam fuga, correndo, e escorregaram nos pedregulhos, mas ambos sofreram apenas poucas escoriações e foram capturados. Eles foram identificados como sendo o maior de nome Felipe Augusto de Oliveira e Y.F.F.A., menor de 16 anos. Em revista pessoal, com Felipe, foram localizados 44 eppendorfs de cocaína, 70 porções de maconha e R\$ 89,00, em uma pochete a tiracolo. Com Y., foram localizadas 128 porções de crack e R\$ 53,00, nos bolsos do moletom que trajava. Questionado, Y. confessou que era seu primeiro dia no tráfico, ganharia R\$ 20,00 por cada mula vendida (que são 26 unidades de crack) e cada pedra estava sendo vendida por R\$ 5,00, por isso tinha dinheiro no bolso. Quanto a Felipe, confessou que tem condenações por tráfico e que a maconha e a cocaína são de sua propriedade, assim como o crack que estava em posse do menor. Não o conhecia dos meios policiais. Foi necessária a utilização de algemas por fundado receio de nova fuga. A genitora do menor, de nome Daiane, foi localizada e compareceu ao distrito, assim como a esposa de Felipe acompanhou sua prisão no local, chegando a quase desmaiar, mas foi socorrida pelo guarda e permaneceu no local dos fatos, cientificada da prisão, comparecendo ao distrito (fls. 04).

Na fase policial, o adolescente Y.F.F.A. falou que, na data dos fatos, estava vendendo drogas para Felipe. Conhece-o há pouco tempo, mas lhe prometeu pagar R\$ 20,00 por cada "mula", que contém 26 unidades cada uma. Cada pedra foi vendida por R\$ 5,00 e por este motivo ele estava com dinheiro no bolso da blusa. Está arrependido. Ao avistar a viatura correu e acabou caindo e ralou os joelhos, mas compareceu ao PS Vila Cristina por praxe (fls. 05).

Em oitiva informal, o adolescente confirmou que estava na prática do tráfico de drogas, com o réu e recebeu remissão com aplicação de medida protetiva de liberdade assistida (fls. 75 do processo nº 1501472-76.2021.8.26.0599, em trâmite perante a Vara da Infância e Juventude local).

A primeira questão a ser analisada nos autos é o envolvimento do réu com a droga apreendida.

O réu, em solo policial, nada disse sobre os fatos. Em audiência, o réu confirmou que parte da droga (maconha e cocaína) estava em seu poder.

Os guardas civis confirmaram que viram o réu e o adolescente em viela, local conhecido por ser ponto de venda de drogas, e, quando ambos avistaram a aproximação da viatura, empreenderam fuga, correndo, o que motivou a abordagem. Na fuga, em razão da qualidade da pavimentação, ambos caíram e foram detidos. Com o réu, os guardas civis encontraram uma pochete a tiracolo, na qual havia 44 microtubos de cocaína, 70 porções de maconha e R\$ 89,00. Com o adolescente, localizaram 128

porções de crack e R\$ 53,00, nos bolsos do moletom. O adolescente contou aos guardas que esse era seu primeiro dia no tráfico de drogas e que ganharia R\$ 20,00 do réu, por cada quite que vendesse, esclarecendo que o dinheiro era produto da venda do entorpecente. Já o réu confirmou